

1500258-32.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... guardava dinheiro proveniente do tráfico e que na residência de seu tio (corrêu Kleber) o restante das drogas estaria armazenado. Kevyn teria, ainda, indicado os endereços, bem como franqueou a entrada dos policiais militares.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que o tráfico de drogas, por ser crime permanente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500258-32.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500258-32.2022.8.26.0626 - Controle nº 2022/001171

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER DIAS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 110/112, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 20h30, na Rua Cordovil Moreira Dadinho, 28, Praia de Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião, KEVYN KENYD LIMA DIAS DOS SANTOS e KLEBER DIAS DOS SANTOS, em unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 61 (sessenta e uma) porções de Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 159,29 (cento e cinquenta e nove gramas e vinte e nove centigramas), 223 (duzentos e vinte e três) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 265,50g (duzentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação preliminar de fls. 18 e laudo pericial toxicológico definitivo de fls. 160/162.

Em razão destes fatos, KEVYN KENYD LIMA DIAS DOS SANTOS e KLEBER DIAS DOS SANTOS foram denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Presos em flagrante delito, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas

(fls. 85/90).

A denúncia foi recebida (fls. 119/120) e os réus foram citados (fls. 132 e 137). Sobreveio resposta à acusação (fls. 143/144), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 146/149). Realização de audiência de instrução, em instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como os réus foram interrogados (fls. 178/181). Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido inserto na denúncia, para que os réus sejam condenados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ao passo que a Defesa, em alegações finais, preliminarmente, alegou violação de domicílio, aduzindo que restou comprovado que o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados se deu de maneira ilegal, pois não haviam circunstâncias que justificassem o ingresso na residência deles, devendo, portanto, ser declarada nula todas as provas produzidas decorrente de tal ilícito. Quanto ao mérito, postulou pela absolvição dos acusados, aduzindo insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postulou, para ambos os réus, a fixação da pena no mínimo legal; em relação ao réu Kevyn, pugnou pelo reconhecimento da menoridade relativa, como atenuante. Requereu a aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei de Drogas). Requereu a aplicação do disposto no artigo 41 da Lei de Drogas, já que os réus, segundo os policiais, teriam colaborado na localização dos entorpecentes. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, também, a isenção da pena de multa, o direito dos acusados de recorrerem em liberdade e, enfim, aplicação do instituto da detração penal.

Encerrada a instrução, foi concedida a liberdade provisória aos réus, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (fls.176/177).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito, de logo, a preliminar de violação de domicílio e prova ilícita arguida pela r. Defesa em sede de Alegações Finais, que aduziu que restou comprovado que o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados se deu de maneira ilegal, pois não houve autorização para o ingresso nas residências deles, devendo, portanto, ser declarada nula todas as provas produzidas decorrente de tal ilícito. A Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso XI, dentre os direitos e garantias fundamentais, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo”, elencando, ainda, algumas hipóteses nas quais se admite exceção a tal princípio, sendo elas: em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, em qualquer horário. Fora de tais hipóteses, somente é permitido o ingresso na residência do indivíduo, sem o seu consentimento e durante o dia, por determinação judicial. Especificamente no caso em tela, segundos uníssonos relatos dos agentes da lei, durante o patrulhamento de rotina um popular noticiou a prática de tráfico pelo local e forneceu as características dos indivíduos. Após breve deslocamento abordaram três indivíduos, sendo os réus e um usuário que afirmou que estava no local para adquirir drogas de Kleber. Em revista pessoal em ambos, localizaram entorpecentes na posse de Kleber (28 porções de cocaína). Kevyn indicou que do outro lado da rua guardava algumas porções de entorpecentes. Kevyn também admitiu que em sua residência guardava dinheiro proveniente do tráfico e que na residência de seu tio (corrêu Kleber) o restante das drogas estaria armazenado. Kevyn teria, ainda, indicado os endereços, bem como franqueou a entrada dos policiais militares. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que o tráfico de drogas, por ser crime permanente (aquele cuja consumação se prolonga no tempo), admite o flagrante a qualquer momento. Desse modo, o agente que guarda ou tem em depósito substâncias entorpecentes está continuamente em flagrante delito.

Nesse sentido a jurisprudência recente: “1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizara prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na

modalidade guardar e manterem depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada" (HC 373.388/RS, DJe 01/02/2017).

E ainda: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 345.424 /SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/08/2016, DJe 16/09/2016)" (HC 326.503/RS, DJe15/03/2017).

Desse modo, a atuação policial não configurou violação de domicílio, pois a prática de crime de tráfico de entorpecentes ou de posse ou porte de entorpecentes para uso pessoal autorizam o flagrante a qualquer tempo, por se tratarem de crimes permanentes, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Ademais, como já mencionado acima, o réu Kevyn indicou os endereços, bem como franqueou a entrada dos policiais militares. Observo que os policiais não possuíam conhecimento do endereço pessoal dos acusados e se não fosse a indicação de Kevyn não teriam se diligenciado às residências deles. Frise-se, por oportuno, que os réus negaram que os policiais invadiram as residências deles.

Quanto ao mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitativa está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 03, boletim de ocorrência de fls. 04/07, auto de constatação preliminar de fl. 18, imagens de fls. 47, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64 e 69, relatório policial (fls. 104/105), laudo químico toxicológico (fls. 160/162) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre as pessoas dos réus.

Na fase inquisitiva, KEVYN KENYD LIMA DIAS DOS SANTOS e KLEBER DIAS DOS SANTOS mantiveram-se calados (fls. 12/13).

KEVYN KENYD LIMA DIAS DOS SANTOS e KLEBER DIAS DOS SANTOS, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao serem interrogados, negaram os fatos que ora lhes são imputados na denúncia. KEVYN disse que estavam na rua no momento em que os policiais os abordaram; tais policiais imputaram-lhes a prática do tráfico de drogas, mas nada de ilícito consigo foi encontrado; o dinheiro que possuía foi levado pelos policiais e estes, momentos depois, retornaram ao local da abordagem com as drogas; afirmou que sofreu violência policial. A Defensora respondeu: afirmou que não informou aos policiais seu endereço residencial. KLEBER disse que os policiais os abordaram e ao serem revistados nada de ilícito foi encontrado; admitiu que os policiais atravessaram a rua, vasculharam o local e ali localizaram entorpecentes; após, foram levados pelos policiais para o alto do morro; nega que os policiais tenham ido até a residência deles; salientou que tem conhecimento de seus direitos e que para ingressarem em sua residência é necessário mandado.

Noutro giro, Osmar Barros Domingues, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: estavam em patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido pelo intenso comércio de drogas, e chegou ao conhecimento da equipe através de denúncia de populares que 03 indivíduos estariam traficando na redondeza; de posse das características dos indivíduos, após breve deslocamento abordaram tais indivíduos, sendo os réus Kevyn e Kleber e o usuário Ricardo (fl. 10) que afirmou estar no local para adquirir drogas de Kleber; em revista pessoal, com Kleber foi localizado certa quantia em dinheiro (R\$ 72,00), além de 28 porções de cocaína; com Kevyn localizaram certa quantia em dinheiro, tendo ele, após entrevista pessoal, indicado o local onde estavam ocultas as drogas (do outro lado da rua), bem como admitiu que em sua residência guardava o restante do dinheiro proveniente do tráfico; Kevyn declinou ainda que o restante das drogas estaria na casa de Kleber, seu tio; ato contínuo, os policiais militares deslocaram até a residência de Kevyn e este franqueou a entrada dos policiais, onde localizaram outra quantia em dinheiro; já na residência de Kleber, foi encontrada uma sacola contendo porções de cocaína e porções maconha; a denúncia indicava as características dos acusados; os demais integrantes da equipe policial já conheciam os acusados. À Defensora respondeu: a residência dos réus está localizada

aproximadamente 500 metros do local da abordagem; os réus não portavam documentos pessoais e ambos autorizaram o ingresso dos policiais às residências deles; por questão de logística dos traficantes, as drogas ficavam na residência de Kleber por ser mais próxima à "biqueira", facilitando, assim, a reposição dos "estoques"; na residência de Kevyn o dinheiro foi encontrado sob o colchão; na residência de Kleber as drogas foram encontradas dentro de um pote de mantimentos, no interior do armário; Kevyn informou aonde as drogas e o dinheiro ficavam guardados, bem como afirmou que ele era o responsável pela venda de maconha e Kleber pela venda de cocaína; o usuário Ricardo afirmou que ambos os réus estavam traficando.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Luiz Daniel Cipolari, em nada divergindo o depoimento de ambos. Salientou que ficou a maior parte do tempo na segurança; acompanhou as diligências às residências dos acusados, mas permaneceu do lado de fora fazendo a segurança; o local da abordagem não é distante da residência deles; Kevyn, que estava sem documentos pessoais, franqueou a entrada dos policiais, bem como disse aonde guardava o dinheiro e também que as drogas ficavam na residência do seu tio, corréu Kleber; ficou na segurança e não estava presente no momento em que Kevyn concedeu a permissão de ingresso à residência dele.

A testemunha Ricardo Rodrigo de Jesus, em solo policial (fl. 10), indagado, às perguntas respondeu: "Que é usuário de cocaína e que na data de hoje foi até a "biqueira" que fica no início da Rua Porto Seguro, local onde foi abordado pelos policiais, para comprar cocaína, de Kleber. Que inclusive já comprou anteriormente deste mesmo indivíduo, cerca de quatro a cinco vezes. Que quanto ao outro indivíduo de nome Kevyn, respondeu que não o conhece."

Pois bem.

A negativa apresentada pelos acusados está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Na fase inquisitiva mantiveram-se calados, já, em juízo, negaram os fatos. Disseram que estavam na rua e foram abordados pelos policiais militares e estes, gratuitamente, imputaram-lhes a prática do tráfico de drogas. Ambos negaram ter informado aos policiais seus endereços residências. Admitiram, entretanto, que os policiais localizaram drogas próximo ao local da abordagem. Kleber ressaltou que tem conhecimento de seus direitos e por isso não forneceu seu endereço e, ainda, que está ciente de que para ingressar em sua residência seria necessário um mandado. As declarações dos réus não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual as versões por eles apresentadas não podem ser aceitas.

Por outro lado, os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Segundos uníssonos relatos dos agentes da lei, durante o patrulhamento de rotina um popular noticiou a prática de tráfico pelo local e forneceu as características dos indivíduos. Após breve deslocamento abordaram três indivíduos, sendo os réus e um usuário de drogas e este afirmou que estava no local para adquirir drogas de Kleber. Em revista pessoal, localizaram entorpecentes na posse de Kleber (28 porções de cocaína). Kevyn indicou que do outro lado da rua guardava algumas porções de entorpecentes. Kevyn também admitiu que em sua residência guardava dinheiro proveniente do tráfico e que na residência de seu tio (corréu Kleber) o restante das drogas estaria armazenado. Kevyn teria, ainda, indicado os endereços, bem como franqueou a entrada aos policiais militares.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a

lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ademais, a testemunha Ricardo Rodrigo de Jesus, em solo policial (fl. 10), admitiu que é usuário de cocaína e que foi até a "biqueira", local onde foi abordado pelos policiais, para adquirir cocaína de Kleber, ressaltando que já comprou anteriormente deste mesmo indivíduo, cerca de quatro a cinco vezes.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Saliente-se que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012). No caso em tela, a comercialização restou configurada, considerando os relatos de o usuário Ricardo de fl. 10.

Por fim, reputo descabida a aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/03, pois a pretensa colaboração do réu Kevyn na investigação, ao indicar onde se encontravam os entorpecentes, não se estendeu ao processo criminal, como exigido no dispositivo legal. Aliás, os réus negaram que de fato indicaram o local onde as drogas estavam guardadas, bem como negaram que forneceram seus endereço, não podem agora reivindicar tal benefício, pois calaram-se no momento oportuno. Tampouco houve indicação dos partícipes ou sequer indicaram o fornecedor das drogas.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação dos acusados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção, passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal, observo em fls. 114/118 que os réus não ostentam maus antecedentes. Entendo, considerando a quantidade de entorpecentes, bem como a diversidade e a natureza das drogas (61 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 159,29 e 223 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 265,50g), de modo que deve ser levada em conta para a fixação da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentando em 1/6, para resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para ambos os réus, vez que idênticas as circunstâncias, nesta fase.

Na segunda fase, não há nenhuma agravante genérica. Com relação ao acusado KEVYN, presente a atenuante da menoridade relativa, assim, retorno a sua pena ao patamar mínimo, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade dos acusados e a ausência de indícios concretos de que se dedicassem às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrassem organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, resultando assim para o acusado KEVYN uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e para o acusado KLEBER uma pena de 01 (um) ano, 11

(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte dos acusados, fixo o regime inicial aberto (artigo 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Para ambos os réus, consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do artigo 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO os acusados KEVYN KENYD LIMA DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e KLEBER DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ambos por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no regime prisional inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Concedo aos réus o direito de permanecerem em liberdade, na hipótese de interposição de recurso, em razão da pena aplicada, por ser primário e, por não mais estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Restou provada a origem ilícita do dinheiro com eles apreendidos, razão pela qual decreto a perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Quanto aos aparelhos celulares apreendidos, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal dos réus, expeça-se o necessário quanto ao dinheiro, ao aparelho celular e às drogas.

Condeno aos réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA